

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제06절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치>
[예상][5.06-2]소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점

《【문제5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 서울 강남구 이하 불상이라고만 기재하였고, 청구원인에는 乙이 돈을 빌려가서 안 갚음이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없자 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음2) 피고 丁에 대한 소장 부분의 송달이 불가능하여 재판장이 주소보정을 명하였음에도 丙이 이에 응하지 않거나 공시송달 요건을 갖추지 못한 경우, 재판장이 행할 수 있는 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점을 소송 계속의 발생 여부와 관련하여 설명하시오.》

<문제5.6의 물음2> 소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점

I. 문제의 제기

- 사안에서 피고에 대한 소장 부분의 송달이 불가능한 상태에서 재판장이 주소보정을 명하였으나 원고가 이에 응하지 않거나 공시송달 요건도 갖추지 못한 상황이다. 쟁점으로 <소장 부분 송달 전후에 따른 소송 계속의 발생 여부를 기준으로 재판장의 소장각하명령과 법원의 소각하판결이 어떠한 차이가 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고에 대한 송달불능 상태에서 주소보정이 이루어지지 않은 경우 소장각하명령과 소각하판결의 차이점을 소송 계속의 발생 여부를 중심으로 설명한다.

II. 소장 부분의 송달과 소송계속의 발생

1. 소장 부분 송달의 의의

- 소장이 접수되면 법원은 이를 심사한 후 지체 없이 피고에게 소장 부분을 송달하여야 한다. 이는 피고에게 방어 기회 제공과 심판 대상 알리는 중요한 절차다.

2. 소송계속의 발생 시기

- 민사소송법상 소송계속은 소장 부분이 피고에게 적법하게 송달된 때에 발생한다. 소송계속이 발생하면 중복소제기 금지, 시효중단 등의 소송법적 효과가 발생하며, 이때부터 사건은 법원의 심판 대상으로서 완전히 정착된다.

III. 소장각하명령 [민사소송법 제254조]

1. 발생 단계 및 사유

- 소장 부분이 피고에게 송달되기 전, 즉 소송계속이 발생하기 전 단계에서 행해지는 조치다. 주소불명 등으로 인하여 소장 부분을 송달할 수 없는 경우 재판장은 주소보정을 명하고, 이에 응하지 않으면 명령으로 소장을 각하한다.

2. 성질 및 불복 방법

(1) 성질

- 재판장 개인의 권한으로 행하는 소송지휘적 처분이다. 소송계속 전이므로 변론을 거치지 않고 서면심사만으로 결정한다.

(2) 불복 방법

- 소장각하명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

IV. 소각하판결 [민사소송법 제219조 등]

1. 발생 단계 및 사유

- 소장 부분이 피고에게 이미 송달되어 소송계속이 발생한 후의 단계에서 행해지는 조치다. 일단 송달은 되었으나 이후 소송요건의 흠결이 발견되거나, 공시송달 요건 미비 등으로 더 이상 절차 진행이 불가능하여 소송 자체가 부적법하다고 판단될 때 법원의 이름으로 내리는 재판이다.

2. 성질 및 불복 방법

(1) 성질

- 수소법원(합의부 또는 단독판사)이 내리는 종국판결이다. 원칙적으로 변론을 거쳐야 하나, 소송요건 흠결이 명백한 경우 변론 없이 판결할 수도 있다.

(2) 불복 방법

- 판결이므로 항소로써 불복하여야 한다.

V. 두 조치의 주요 차이점 비교

1. 주체와 형식의 차이

- 소장각하명령은 재판장 개인이 내리는 명령인 반면, 소각하판결은 당해 사건의 수소법원이 내리는 판결이다.

2. 소송계속 발생 여부에 따른 구별

(1) 소장각하명령

- 소장 부분이 송달되지 않아 소송계속이 발생하기 전의 조치다. 따라서 시효중단이나 제척기간 준수의 효력은 소급하여 소멸하게 된다.

(2) 소각하판결

- 이미 소장 부분이 송달되어 소송계속이 발생한 상태에서 내리는 재판이다. 즉, 법원이 사건을 수리하여 심리에 들어갔으나 형식적 요건 미비로 본안 심리를 거절하는 것이다.

3. 사안의 경우

- 丙이 丁의 주소를 보정하지 못해 소장 부분 자체가 송달되지 못한 단계라면 재판장은 소장각하명령을 내린다. 그러나 일단 송달은 되었으나 그 주소가 허위임이 판명되거나 공시송달 요건을 갖추지 못해 향후 절차 진행이 불가능한 사유가 소송계속 발생 후에 확인되었다면 소장하판결의 대상이 된다.

Ⅵ. 결론

- 소장각하명령과 소장하판결은 모두 소송의 흠결을 이유로 절차를 종료시키는 재판이라는 공통점이 있으나, 그 시점과 주체에서 명확히 구분된다. 소장각하명령은 소송계속 전 재판장의 권한으로 행하는 명령이며, 소장하판결은 소송계속 후 수소법원이 내리는 종국판결이다. 丙의 사례와 같이 주소보정 불이행 및 송달불능의 상황은 대개 소송계속 전 단계에 해당하므로 소장각하명령이 원칙적인 조치가 될 것이나, 구체적인 송달 여부에 따라 그 형식이 달라질 수 있다. 이를 정확히 구분하는 것은 원고의 불복 방법과 시효중단 등 실체법적 효과를 판단하는 데 있어 필수적이다.